

# 第40問

Xは、スナックを経営する甲女に好意を抱き、高価な時計、ネックレス等をたびたびプレゼントしていた。しかし甲は、それらの品は受け取っていたものの、Xと個人的に交際する気は全くなく、デートの誘いを受けても、「また今度」などとはぐらかしていた。ある日Xは、スナックで酒を飲み、他の客もいなかったことから、甲に交際を強く迫ったが、甲から、他に交際している男性がいるのでつきあえないといわれたため、頭に血が上り、強いて姦淫（注：現行法では「性交」（177条）、以下略）してしまおうと考え、甲に突然飛びかかり、その顔面を殴打して、負傷させた上、さらに頸部を両手で締め上げた。これによって、甲はぐったりして、人事不省に陥った。Xはこれを見て、甲を殺害してしまったと思い込み、犯行がばれないように強盗の仕業に見せかけようと考えて、店内を荒らし、甲が身につけていた高価な装飾品などを取り、また、レジスターをこじ開けて金品を持ち出した。

以上の事案におけるXの罪責について論じなさい。

（上智大学法科大学院 平成20年度 改題）

## 第1 甲女を姦淫しようとして負傷させた行為

まず、姦淫の意図で、甲に飛びかかり、顔面を殴打した上負傷させた行為は、強制性交致傷罪（181Ⅱ）に該当する。性交自体は未遂でも、傷害結果が発生すれば、同罪が成立する。

## 第2 装飾品を奪い、レジから金品を持ち出した行為

- 次に、甲の身につけていた高価な装飾品及びレジスター内の金銭を持ち去った行為については窃盗罪（235）の客観的構成要件要素を充足する。
- もっとも、Xは甲が死亡したと思い込んでいるから、窃盗罪の故意が認められないのではないか（**論点** 死者の占有 **論** 司H29）。

Xの認識では先の暴行によって甲が死亡し、その甲から財物を奪取するというものである。このようなXの認識を基準とするといかなる犯罪が成立するのか。

この点について、判例（最判昭41.4.8【百選Ⅱ29】）は、「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである。そうすると、被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は、これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべきであるから、右奪取行為は、占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成するものと解するのが相当である」と述べている。

これは、死者に占有は認められないとしても、行為者との関係では、一連の行為を全体として観察し、生前の占有を侵害したと認められることを条件として、窃盗罪の成立を認める見解であると解されている。

この見解によれば、本問Xの認識を基準としても、窃盗罪の構成要件要素の認識は備わっており、窃盗罪の故意を肯定するのに問題はない。

- ただ、Xは自己の姦淫行為の発覚を防ぐためにこのような行為に及んでおり、いわゆる不法領得の意思が認められないとも思われる（**論点** 不法領得の意思 **論** 司H27,H29,I8H1-2,H19-2）。

不法領得の意思は、一般に、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用もしくは処分する意思と定義されている（大判大4.5.21）。

これは大別して、①所有権者として振る舞う意思、②経済的用法に従って利用・処分する意思とで構成される。

本問では、①は問題ないが、②は証拠隠滅目的で窃盗行為が行われていることから、認められないのではないかが問題となる。

この点について、物取りの犯行を装うために財物を持ち去ったという事案において、不法領得の意思を肯定した裁判例がある（東京高判平12.5.15。ただし、後に領得する意思もうかがわれる事案）ものの、学説では批判的な見解も多い。

答案例では、同高裁にしたがって、窃盗罪を成立させた。

総合 197 頁 論証 83 頁

総合 198 頁 論証 85 頁

### 第3 罪数

以上から、Xには強制性交致傷罪と窃盗罪が成立し、両者は併合罪の関係に立つ（45前段）。

## 答案構成

第1 甲女を姦淫しようとして負傷させた行為

1 強制性交等致傷罪（181Ⅱ）の成否

↓

2 強制性交等罪の未遂認定

↓

3 致傷認定

↓

強制性交等致傷罪成立

第2 装飾品を奪い、レジから金品を持ち出した行為

1 窃盗罪（235）の成否

↓

強盗は不成立

↓

2 窃盗罪の客観的構成要件要素は充足

↓

故意（38Ⅰ）の成否

↓

占有侵害の認識が必要

↓

Xの認識を基準として占有侵害の認識が認められるか

↓

死者の占有

↓

一連の行為を全体として観察し、生前の占有を侵害したと認められるか

↓

あてはめ

↓

Xの認識を基準としても占有侵害の認識あり

↓

故意あり

↓

3 不法領得の意思

↓

権利者排除意思、利用処分意思

↓

あてはめ

↓

不法領得の意思あり

↓

4 窃盗罪成立

## 第3 罪数

強制性交等致傷罪及び窃盗罪が成立する



## 第1 甲女を姦淫しようとして負傷させた行為

1 Xは、甲を姦淫してしまおうと考え、甲に飛びかかって、顔面を殴打して負傷させ、頸部を両手で締め上げている。この行為について、強制性交致傷罪（181条2項）が成立することが考えられる。

2(1) 強制性交罪の手段である「暴行」とは、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものでなくてはならない。

Xは、甲に突然飛びかかり、顔面を殴打して負傷させ、頸部を両手で締め上げている。一般的な男性と女性の体格差も考慮すれば、このような暴行を加えれば、相手方の反抗は著しく困難になるといえるから、「暴行」に該当する。

(2) しかし、Xは結局「性交」に至っていないから、強制性交罪の未遂罪（180条、177条）が成立するにとどまる。

3 上記Xの暴行によって甲は負傷しているから、「177条……の罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた」（181条2項）といえ、強制性交致傷罪が成立する。

## 第2 装飾品を奪い、レジから金品を持ち出した行為

1 Xは、人事不省に陥った甲が死亡したと誤信し、強盗の仕業に見せかけようとして装飾品やレジ内から金品を持ち出している。この行為について、窃盗罪（235条）の成立可能性がある。なお、強盗罪（236条1項）の成立余地はない。強盗罪は暴行・脅迫を手段として他人から財物を強取することにその本質がある以上、暴行・脅迫時点において財物奪取の意思が必要だからである。

1

2(1) まず、甲が身につけていた高価な装飾品及びレジスター内の金銭を持ち去った行為については、「他人の財物を窃取した」として、窃盗罪の客観的構成要件要素を充足する。

(2)ア しかし、Xは、甲が死亡してしまったと誤信しているため、窃盗罪の故意（38条1項）が認められるか問題となる。

故意とは、構成要件該当事実に対する認識であり、窃盗罪の実行行為である「窃取」とは、占有者の意思に反して、他人の所有する財物を自己又は第三者の支配下に移すことである。したがって、窃盗罪の故意が認められるためには、占有侵害の認識が必要である。

そこで、Xの認識した甲死亡という事実を基準としてもなお、甲が装飾品やレジ内の金員を占有していたといえるか。

イ 確かに、死者自体に占有は認められないが、行為者との関係では、一連の行為を全体として観察し、生前の占有を侵害したと認められる限度では、生前の占有がなお継続して刑法上の保護に値すると解する。

ウ 本問では、Xが装飾品等を奪ったのは、甲が人事不省に陥った直後であり、また、同一の部屋内における犯行である。

そうだとすれば、Xとの関係では、一連の行為を全体として観察し、甲の生前の占有を侵害したと評価することができる。

したがって、仮に甲が死亡していたとしても、なお甲の装飾品等に対する占有が認められるのだから、Xの認識を基準としても、占有侵害の認識が認められ、窃盗罪の故意を認めることができる。

2

3 もっとも、Xは、犯行を隠蔽するために装飾品等を奪ったものであり、不法領得の意思を欠くのではないか。

領得罪の成立に際しては、不法領得の意思の有無を判断する必要がある。かかる主観的超過傾向を不要とすれば、不可罰的な使用窃盗と窃盗罪（235条）との区別、また、窃盗罪と毀棄罪（258条以下）との区別が困難になるからである。

そして、その内容としては、上記区別の必要性に鑑み、①権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、②その経済的用法に従いこれを利用・処分する意思であると解する。

本問では、装飾品等に対する利用阻害が生じることは明らかなから、権利者排除意思は問題なく認められる。

一方で、利用処分意思はどうか。確かに、装飾品等を犯行の隠蔽目的で奪っているものの、単純に毀棄・隠匿目的で奪ったとは認められないから、なお経済的用法に従って利用処分する意思を認めることができる。

4 したがって、Xには窃盗罪が成立する。

### 第3 罪数

Xには強制性交致傷罪（181条2項）と窃盗罪（235条）が成立し、両者は併合罪（45条前段）となる。

以上